

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - *In dubio pro disciplinado*

El cargo formulado fue por falsedad ideológica consistente en que el disciplinado afirmo en el auto y acta de inspección que había efectuado inspección física de una mercancía identificada con el número de transporte 00SU6006189550 y número de manifiesto 81000147. Sin embargo, el disciplinado fue absuelto porque al valorar el material probatorio no se superaron dudas insuperables respecto de la ocurrencia del hecho. En tal sentido pudo establecerse que se encontraron elementos suficientes para resolver *in dubio pro disciplinado*, por cuanto no fue posible superar las dudas sobre la ocurrencia del hecho o la autoría del disciplinado.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 9

IN DUBIO PRO DISCIPLINADO – Duda razonable

“...no existe la certeza de que el investigado sea autor de las descripciones típicas consagradas en la ley como delitos de falsedad ideológica y prevaricato, por lo tanto, ante las dudas generadas, se aplicará el principio de LA DUDA A FAVOR DEL DISCIPLINADO, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 734 de 2002.

Para la aplicación de este principio, emanado de la presunción de inocencia, recalca el Despacho, se requiere que la duda sea razonable y que no haya modo de eliminarla, y para el caso en cuestión, si bien, se repite, se demostró que dentro del proceso aduanero seguido en la Dirección Seccional de Aduanas de Bucaramanga, con motivo de la incautación de mercancía consistente en 571 televisores marca Silver, de 14”, se allegaron las actas de legalización y el auto acta de inspección en cuyo trámite se hizo partícipe el señor XXXX, para 298 televisores de las mismas características, no fue posible establecer si el disciplinado, en verdad, no realizó la diligencia de inspección de la mercancía en la ciudad de Barranquilla, lo que dio lugar a la imputación formulada. Como corolario, se procederá a ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD al señor XXXX, en su condición de funcionario de la DIAN, Dirección Seccional Aduanas de Barranquilla, por las irregularidades endilgadas.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 9

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-249
Número y fecha del fallo:	17413-09, del 5 de abril de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Cumplidas las etapas de rigor y habiéndose dado traslado para alegatos de conclusión, mediante auto del 15 de marzo de 2013, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 734 de 2002, los Decretos 4173 de 2011 y 0985 de 2012, procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-249.

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 1011-06 de 1 de julio de 2011, se citó a audiencia al señor (XXXX), formulándosele los cargos disciplinarios que a continuación se indican:

Cargo 1.

"(...) El señor XXXX, en calidad de funcionario de la UAE DIAN, el día 4 de junio de 2008, consignó una falsedad en el Auto y Acta de Inspección No. 955 (visto a folio 44). La falsedad imputada, consistente en que el disciplinado afirmó en dicho documento, que había efectuado inspección física de una mercancía identificada con el número de transporte 00SU6006189550 y No. De manifiesto 810000147, circunstancia que se probó como no cierta y que presuntamente compromete su responsabilidad disciplinaria.

Cargo 2

El señor XXXX, en calidad de funcionario de la UAE DIAN, el día 4 de junio de 2008, profirió un acto administrativo manifiestamente contrario a la Ley, toda vez que ordenó mediante Auto y Acta de Inspección No. 955 (folio 44) el levante de una mercancía, sin acatar lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999". (...)"

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Del Problema Jurídico: Le corresponde a esta Subdirección demostrar con certeza la materialidad de los hechos y su autoría, lo cual implica probar que el resultado de la infracción disciplinaria objeto de cargos, obedece a la existencia de un comportamiento de acción o de omisión realizado por el implicado ya sea a título de dolo o de culpa, y que su actuar no se estructura en ninguna causal de justificación.

De los hechos materia de cargos: En el caso objeto de análisis, se tiene que en los cargos formulados en contra del señor XXXX, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, se le cuestionó por la presunta consignación de una falsedad en el Auto y Acta de Inspección No. 955, falsedad consistente en que en dicho documento se consignó que había realizado la inspección

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-249

física de una mercancía identificada con el número de transporte 00SU6006189550 y número de manifiesto 810000147, circunstancia que, se dijo, se probó como no cierta. Se puso de presente en el pliego de imputaciones, que el funcionario pudo incurrir también en comportamiento constitutivo del delito de prevaricato, al ordenar el levante de una mercancía sin acatar lo dispuesto por el numeral tercero del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999.

De los descargos y de los alegatos de conclusión: El señor apoderado al rendir los descargos y al presentar alegaciones finales, realizó la defensa dentro del contexto propio de la actuación desplegada por su defendido, esto es, la relacionada con la declaración de importación modalidad legalización No. 07925270187071 del 4 de junio de 2008, con la correspondiente orden de levante de la mercancía en ella referida, además de la expedición del Auto y Acta de Inspección No. 955 de la misma fecha, todo dentro del marco impuesto por el expediente número DM 080801980, de cuyo trámite derivó la noticia disciplinaria que a la postre dio lugar a la formulación de cargos contra el funcionario investigado.

De los presupuestos para sancionar: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la ley 734 de 2002: *"Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado"*.

Por su parte el artículo 142 de la misma ley dice que: *"No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado"*

.

Del fallo absolutorio: Al examinar el asunto, encuentra este Despacho que desde el punto de vista probatorio, no obra plena prueba, en lo atinente a la demostración plena de los hechos y de la culpabilidad del implicado, veamos:

Ciertamente obran en el expediente los documentos que dan cuenta de las diligencias desplegadas por el señor XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, así:

-Declaración de importación en la modalidad de legalización No. 07925270187071, nombre del declarante XXX, con aceptación No. 022008M0001323, levante No. 022008M9100000158, del 4 de junio de 2008, que en el acápite de descripción de la mercancía hace referencia a televisores a color tipo pantalla convencional en vidrio, tamaño 14", en cantidad de 298. Tal declaración corresponde a la legalización del formulario anterior No. 022008100080056, de fecha 30 de mayo de 2008 (folio 33, entre otros).

-Auto y Acta de Inspección No. 955 del 4 de junio de 2006, donde se indica que se procede al levante No. 022008M9100000158, en los términos del numeral 3, artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, con sus modificaciones. Funcionario comisionado XXXX (fl. 38, entre otros).

También se aprecia el acta de declaración de importación antecedente a la legalización, número 022008100080056-5, en la cual figura como funcionario comisionado el señor XXX, y donde en la

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-249

descripción de la mercancía se refieren 298 televisores a color tipo pantalla de cristal líquido, tamaño 14", sistema de control remoto.

Igualmente, y de la manera como se puso de presente en el acápite de pruebas de este proveído, con motivo de la actuación disciplinaria surtida en contra del señor XXXX, se allegó al plenario copia del expediente No. DM080801980, relacionado con la dejación a disposición de la Jefatura Grupo Infracciones Aduaneras, de mercancía por parte de la Policía Nacional Seccional Tránsito y Transporte de Santander, el 2 de junio de 2008, con acta de incautación del 4 del mismo mes y año, y orden de decomiso de mercancía consistente en 571 televisores marca Silver de 14". En dicho documento, tal como se advirtió en acápites previos, aparece claro que con ocasión de la diligencia de incautación, la Sociedad Intermediaria Aduanera MEDINA GÓMEZ LTDA, el 4 de junio de 2008, allegó al Grupo Operativo de Bucaramanga, la declaración de importación con número de aceptación 022008M0001323, en la que aparece como motivo la legalización del formulario anterior 022008100080056, para 298 televisores a color tipo pantalla convencional en vidrio, marca Silver.

También está claro que la mencionada sociedad intermediaria aduanera, durante todo el curso de la actuación aduanera que culminó con la orden de decomiso de la mercancía, entregó como documentos soportes de la legal introducción al país de los televisores incautados, las declaraciones antes anunciadas, en las que aparecen como funcionarios responsables los servidores de la DIAN, señores XXX (la declaración con número de formulario 022008100080056-5, del 30 de mayo de 2008) y XXXX (la declaración No. 07925270187071 y el Auto y Acta de Inspección No. 955, los dos del 4 de junio de 2008).

De dichos documentos se infiere que el 30 de mayo de 2008 la Sociedad Intermediaria Aduanera MEDINA GÓMEZ LTDA, presentó la declaración de importación inicial No. 022008100080056-5, la cual amparaba 298 televisores de 14" LCD, seleccionada por el sistema para inspección física, habiéndose otorgado levante físico por parte del señor XXX. A propósito de esta declaración, el apoderado del funcionario investigado, doctor XXX, advierte la necesidad de investigación de la actuación surtida por el señor XXX, en tanto en el mercado no existen televisores LCD de 14", con pantalla de cristal y, en consecuencia, en su sentir, se debió rechazar el levante.

Explicó igualmente el mismo doctor XXX, afirmación coincidente con el dicho del investigado en diligencia de injurada, que días después a dicha actuación, la SIA MEDINA GÓMEZ presentó declaración de corrección para enmendar el error de descripción de la mercancía, actuación asignada al señor XXX, quien explicó a la sociedad usuaria que para subsanar el error de descripción sólo se podía proceder a través de una declaración de legalización y que la declaración de corrección que se le puso de presente no producía efecto alguno. Por este motivo, aclaró el mismo apoderado, el 4 de junio de 2008 la SIA MEDINA GÓMEZ presentó declaración de legalización manual, tras la cual se comisionó al señor XXXX para la inspección correspondiente, cumplida en esa fecha, como consta en el Auto Acta No. 955.

Las anteriores afirmaciones de defensa fueron confirmadas en el curso de la actuación por el propio investigado en diligencias de versión y ampliación cumplidas en la forma advertida en líneas antecedentes, y por quienes para la época de los hechos fungieran como Jefe de la División

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-249

de Servicio al Comercio Exterior de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, y el Coordinador del Centro de Servicios Aduaneros CESA, respectivamente. Dichos funcionarios fueron coincidentes en reconocer la posibilidad de presentación de declaraciones de legalización de modo manual, aceptando el primero de ellos que comisionó al funcionario aquí investigado para la realización de inspección física mediante Auto del 4 de junio de 2008, diligencia que, según se lee en el acta No. 955, se materializó en esa misma fecha, documento suscrito por el citado funcionario inspector, señor XXXXFONTANILLA.

De la misma forma, como antes se señaló, mediante oficio 080-02-068-197-303 del 21 de julio de 2008, el doctor XXX, Jefe Grupo de Importación de la Administración de Aduanas de Barranquilla, en atención a la solicitud de verificación del Auto Acta de inspección No. 955 del 4 de junio de 2008, informó a la Jefe de Grupo Operativo de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la Administración de Aduanas de Barranquilla, que dicha acta de inspección se realizó efectivamente en esa Administración y precisó que por tratarse de una declaración manual, se seleccionó para inspección física.

En las citadas condiciones, si bien es cierto, obran en el expediente los documentos que dan cuenta de la presentación, con fines de legalización, de la mercancía incautada en carretera, vía La Lizama San Alberto Km. 37, sitio Peaje La Gómez, esto es, la declaración de legalización del 4 de junio de 2008 a cargo del señor XXXX y la anunciada acta de inspección No. 955, no es posible a estas alturas mantener la imputación formulada al investigado, consistente en la presunta falsedad ideológica en documento público, con la comisión del presunto delito de prevaricato, tachas derivadas de la afirmación en la referida acta de inspección No. 955, que se había efectuado la inspección física de la mercancía, cuando tal actuación no tuvo lugar, conclusión a la que se llegó porque los televisores incautados, para la fecha de la realización de la actuación, se encontraban en la ciudad de Bucaramanga, no en Barranquilla.

Lo anterior, en tanto, como se deriva del material probatorio disponible, no obstante la incorporación al expediente aduanero seguido en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, de las anunciadas actuaciones a cargo del señor XXXX, con fines de legalización de la mercancía incautada, consistente en televisores de 14", tal circunstancia no desdibuja, per se, la declaración de importación en la modalidad de legalización-con levante, por él autorizada, ni tampoco la diligencia de inspección que en documento se dice realizó. Esto especialmente porque, no se dispone de elementos probatorios, como planillas de ingreso de mercancía, al depósito Almagrán de la ciudad de Barranquilla, del ingreso del funcionario XXXX a las bodegas con fines de cumplimiento de la comisión de inspección física de mercancías, ni tampoco el reporte que se debe tener en la DIAN, en tratándose en este caso de declaración de legalización manual, como antes se señaló.

Igualmente, si bien a folio 90 del expediente, se lee la comunicación de fecha 4 de junio de 2008 suscrita por el señor LUIS A. GONZÁLEZ C., dirigida a la División de Comercio Exterior, señor XXXXFONTANILLO IGIRIO, en la que se dice expresamente que: "Por medio de la presente certifico que la mercancía Nacionalizada mediante Declaración de importación No. 022008100080056-5, fue remitida a la ciudad de Bogotá D.C de donde se repartirá por distintas ciudades del país", con la precisión de que tal certificado se expide de acuerdo con lo previsto en

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-249

el parágrafo 2 del artículo 21 del Decreto 2557 de julio de 2007, para poder presentar la declaración de legalización, para el Despacho tal documento ofrece dudas en cuanto a su recepción por parte del destinatario, especialmente porque el mismo carece de sellos y no cuenta con constancia alguna de radicación o inclusión en algún trámite.

Para el Despacho, resulta incomprensible que a propósito de la legalización de la mercancía incautada en el peaje La Gómez, por parte de la Policía de Carreteras Unidades Móviles Judiciales, consistente en 571 televisores convencionales de 14" marca Silver con valor estimado de \$150.000.000, se hubieran aportado declaración y Auto Acta de inspección correspondiente a la legalización de 298 televisores, con valor distinto al ya anunciado, aunque de las mismas características referidas; Igualmente, no se entiende la razón del error en la descripción de la mercancía en el acta de declaración de importación correspondiente al formulario 022008100080056-5, con levante autorizado por el funcionario XXX el 30 de mayo de 2008, que a la postre determinara las actuaciones surtidas por el señor XXXX, aquí investigado, según se lee en los documentos aportados al plenario, como ya se dijo.

Dentro de dicho contexto, se advierte la existencia de duda no superable, en los términos de las probanzas disponibles, en torno a la verdadera materialización de la inspección física de la mercancía correspondiente al acta de importación con aceptación No. 022008M0001323, de lo que surgió el reproche formulado al aquí investigado, pues pese al esfuerzo desplegado, además de las falencias probatorias antes anotadas, no se pudo escuchar en diligencia de declaración juramentada a la representante legal de la SIA MEDINA GÓMEZ INTERNACIONAL LTDA., ni a la persona que para la época de los hechos ostentaba la calidad de jefe de la bodega del depósito ALMAGRÁN de Barranquilla, además de que, como antes se puntualizó, no fue posible verificar en libros de registro o ingreso al depósito, la entrada del funcionario comisionado para la inspección con fines de revisión de la mercancía el 4 de junio de 2008. Ello, no obstante, aclara esta Subdirección, sin desconocer las pruebas testimoniales y documentales que hablan en favor del investigado.

De la anterior suerte, tiene presente el Despacho que para efectos de proferir fallo sancionatorio, se requiere la existencia de prueba suficiente e idónea de los hechos y de la culpabilidad del investigado, la cual es elemento esencial para deducir su responsabilidad y, por ende, inequívocamente debe demostrarse probatoriamente que el resultado, producto del comportamiento que se le endilga, no solamente existió, sino que además es consecuencia de su actuar -acción u omisión-, y fue realizado a título de dolo o de culpa.

En tales circunstancias, resultaría contrario a los principios que rigen las reglas de la sana crítica, concluir que la mera existencia de los documentos de la autoría del señor XXXX, referidos a la legalización de 298 televisores, según trámites adelantados en la Dirección de Aduanas de Barranquilla, dentro del expediente aduanero seguido con ocasión de la incautación de 571 televisores en el departamento de Santander, es suficiente para concluir que dicho funcionario es responsable de la realización de los comportamientos que se le endilgan, pues, si bien al momento de la evaluación de la investigación se dieron los presupuestos para la formulación de cargos, por considerar que objetivamente se hallaba demostrada la falta y la presunta responsabilidad del implicado, también lo es que el fallo sancionatorio debe soportarse en

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-249

pruebas que conduzcan a la certeza de la responsabilidad subjetiva del acusado, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 734 de 2002, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, lo cual implica la demostración inequívoca de la culpabilidad.

Así las cosas, y considerando que las pruebas deben valorarse teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la ley 734 de 2002, que dispone que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, este despacho advierte la carencia de los elementos de juicio en que se funde la certeza de la responsabilidad del señor XXXX, genera la existencia de duda probatoria que debe resolverse a su favor, lo que determina la necesidad de proferir fallo absolutorio y, en consecuencia, este despacho procederá en tal sentido.

De otra parte, se evidenció en el curso de la actuación que pudieron existir irregularidades imputables al funcionario XXX, quien avaló el levante de la mercancía descrita en el acta de importación con número de formulario 022008100080056-5, diligencia cumplida el 30 de mayo de 2008, pues al momento de describir la mercancía pudo incurrir en comportamiento irregular, lo que de manera posterior, fue corregido por el señor XXXX, aspecto que no generó averiguación alguna. Tampoco aparece en el expediente prueba de actuación surtida en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, referida a la presentación de informe ante la autoridad penal, con motivo de las inconsistencias palpables en el proceso aduanero No. DM080801980, tendiente a demostrar la legalidad de introducción al país de los 571 televisores incautados en carreteras del departamento de Santander, cuando quiera que dentro del mismo se aportó un acta en la que se refieren 298 unidades.

Se advierte entonces, la necesidad de compulsar copias de esta averiguación a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera y a la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para que, en atención a sus competencias, definan lo que corresponda y, de ser necesario, formulen las quejas o denuncias a que haya lugar.

A manera de conclusión, se destaca que no existe la certeza de que el investigado sea autor de las descripciones típicas consagradas en la ley como delitos de falsedad ideológica y prevaricato, por lo tanto, ante las dudas generadas, se aplicará el principio de LA DUDA A FAVOR DEL DISCIPLINADO, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 734 de 2002.

Para la aplicación de este principio, emanado de la presunción de inocencia, recalca el Despacho, se requiere que la duda sea razonable y que no haya modo de eliminarla, y para el caso en cuestión, si bien, se repite, se demostró que dentro del proceso aduanero seguido en la Dirección Seccional de Aduanas de Bucaramanga, con motivo de la incautación de mercancía consistente en 571 televisores marca Silver, de 14", se allegaron las actas de legalización y el auto acta de inspección en cuyo trámite se hizo partícipe el señor XXXX, para 298 televisores de las mismas características, no fue posible establecer si el disciplinado, en verdad, no realizó la diligencia de inspección de la mercancía en la ciudad de Barranquilla, lo que dio lugar a la imputación formulada. Como corolario, se procederá a ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD al señor XXXX, en su

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-249

condición de funcionario de la DIAN, Dirección Seccional Aduanas de Barranquilla, por las irregularidades endilgadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, al señor XXXX, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para la época de los hechos Analista III, Código 203, Grado 03, en ejercicio de funciones en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta decisión al disciplinado XXXX y/o a su apoderado, en los términos de Código Disciplinario Único.

TERCERO: Teniendo en cuenta que la presente investigación, se inició con base en informe de funcionario público de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, no hay lugar a la notificación de quejoso, en virtud de lo cual en firme esta decisión archívense las diligencias.

CUARTO: Por conducto de la Secretaría Técnica de esta Subdirección, **COMPULSAR COPIAS DE LA ACTUACIÓN** para que las Subdirecciones de Gestión de Fiscalización Aduanera y de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, acorde con sus competencias, definan la procedencia de acciones concretas o investigaciones disciplinarias contra funcionarios de esa entidad.

QUINTO: Por intermedio de la Secretaría Técnica de esta Subdirección, **INFÓRMESE** a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para que se hagan las comunicaciones y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Marcela Rojas Cárdenas

Revisó: Andrés Felipe Vásquez Umaña